

0005692-21.2015.8.26.0659

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Marcelo Holanda

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... já decidiu o E. STJ:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo - 1ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Jardim Brasil - CEP 13289-086, Fone: (19) 3876-3616,

Vinhedo-SP - E-mail: vinhedo1@tjsp.jus.br

0005692-21.2015.8.26.0659 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0005692-21.2015.8.26.0659

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Soares Guimarães

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

LUCIANO SOARES GUIMARÃES e EDNEI SOARES GUIMARÃES foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º incisos I e II, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 28/06/2015, por volta das 19:15 horas, na Rua Zilá Correa Fernandes da Silva, próximo ao nº 354, Jardim Nova Palmares, Vinhedo/SP, agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, R\$160,00 da empresa Rápido Luxo Campinas, e R\$ 60,00 de David Sabino de Mello.

A denúncia foi recebida em 31/10/2016 (fls. 52).

Luciano foi citado pessoalmente (fls. 149), e apresentou resposta à acusação (fls. 155/159).

Em relação a Ednei, citado por edital, foi declarada a suspensão do processo e do prazo prescricional bem como determinado o desmembramento do processo prosseguindo-se aqui apenas em relação a Luciano (fls. 168/169, 205/206 e 251).

Durante a instrução foi ouvida a vítima por meio de CP e, ao final, o réu foi interrogado perante este juízo.

Em alegações finais, o representante do MP pediu a procedência da ação e a defesa

pediu a nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico, a absolvição do réu e, alternativamente, em caso de condenação, a aplicação da pena nos patamares mínimos legais (fls. 260/264 e 275/284).

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime está comprovada pelo relato da vítima que disse tanto na fase policial como em juízo que seus bens foram subtraídos (fls. 07 e 255).

O declarante David Sabino de Mello disse que trabalhava na linha 406, como motorista de ônibus, quando perto da Rodoviária um passageiro deu o sinal de desembarque. O declarante disse que parou para o desembarque do passageiro e dois indivíduos entraram no ônibus e anunciaram o assalto. O declarante disse que um dos autores estava armado, o que ficou na porta do ônibus. O declarante disse que os autores dos fatos levaram cerca de R\$ 200,00. O declarante disse que na Delegacia reconheceu com certeza um dos indivíduos, aquele que entrou no ônibus. O declarante disse que reconheceu a pessoa que aparece no vídeo durante a audiência de instrução como sendo a pessoa que entrou no ônibus para pegar o dinheiro. O declarante disse que percebeu que o outro indivíduo estava armado porque notou um volume diferente em sua mão, dando a entender que estava com uma arma de fogo próximo à cinta e exigindo o dinheiro várias vezes. O declarante disse que o dinheiro estava no meu bolso e de lá foi pego pelo indivíduo (fls. 255).

O réu Luciano negou a autoria dos fatos na fase policial (fls. 42).

O réu Luciano Soares Guimarães também foi interrogado em Juízo e declarou que não foi o autor desse roubo. O réu disse que foi réu confesso em relação à outros fatos, mas não cometeu esse assalto. O declarante disse que não sabe dizer quem foi o autor dos fatos. O declarante disse que na ocasião dos fatos estava em casa e não conhece a vítima. O réu disse que não tem nada contra ele. Soube que Ednei, seu sobrinho, foi para o sul de Minas Gerais, levado para a família, porque estava envolvido com drogas. O réu disse que está preso hoje por assaltos à farmácias em 2015 (fls. 230/213).

Entretanto, a acusação, no que diz respeito à prova da autoria, está fundada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial pela vítima (fls. 08) em reconhecimento pessoal realizado durante a instrução processual em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

O réu não foi submetido a reconhecimento pessoal pela autoridade policial.

Na fase processual a vítima apontou o réu como autor dos fatos. Mas o reconhecimento pessoal do réu pela vítima no Juízo deprecado foi obedecido ao disposto no art. 224 do CPP.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e o reconhecimento pessoal na forma realizada na fase processual não podem ser admitidos como provas suficientes para condenação no caso concreto.

Primeiro porque os indícios de autoria e de materialidade colhidos na fase policial serviam à propositura da ação penal, mas não podem fundamentar a condenação do réu (art. 155 do CPP).

Segundo porque o reconhecimento pessoal ou fotográfico, conforme entendimento atual do E. STJ, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AFIRMAÇÃO DA VÍTIMA QUE O ACUSADO ERA SEU CONHECIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando

corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, destacando-se que o ora acusado era conhecido, razão pela qual não correu quando ele foi em sua direção. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). Grifo nosso.

No caso concreto não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP em relação ao reconhecimento fotográfico ocorrido na fase policial que se limitou à exibição de imagens à vítima (fls. 08/10), nem em Juízo, em que se limitou à indagação feita à vítima se a pessoa que estava em Hortolândia, preso, seria o réu, seguida da resposta afirmativa dada pela vítima (fls. 255).

Terceiro porque a fotografia nem sempre representa com fidelidade as exatas feições dos fotografados, sujeitando-se à influência de fatores técnicos como a qualidade dos instrumentos e materiais empregados, ou à habilidade do fotógrafo.

Segundo ADALBERTO JOSÉ Q. DE CAMARGO ARANHA (Da Prova do Processo Penal, Saraiva, 5ª edição, 1999, página 214), "o maior e melhor fator de reconhecimento é a fisionomia motriz, isto é, as características individuais de cada ser como o andar, o gesticular, a atitude, a feição, a postura, etc.", o que apenas é assegurado pelo reconhecimento pessoal certo, isento de dúvidas.

Por esses motivos, não se pode atribuir ao reconhecimento fotográfico valor absoluto. Nesse sentido já decidia o E. Tribunal de Alçada Criminal:

"PROVA - Reconhecimento fotográfico - Valor - O reconhecimento fotográfico deve ser levado em consideração no exame da prova, mas não com absoluta exclusividade, pois para referendá-lo exige-se a presença de outros elementos de convicção." (Apelação n.º 705.825/1, Julgado em 21/06/1.994, 3ª Câmara, Relator: - Carlos Bueno, RJDTACRIM 28/214).

"PROVA - Reconhecimento fotográfico - Inexistência de outros fatores a alimentar a certeza dessa modalidade probatória - Condenação - Impossibilidade: - Inteligência: art. 386, VI, do Código de Processo Penal - O reconhecimento fotográfico, quando inexistentes outros fatores a alimentar a certeza dessa modalidade probatória, não pode servir de suporte básico para uma condenação, em face das variações fisionômicas do próprio reconhecido, como também pelas condições da foto e pela indução a que é levado, algumas vezes, o identificador." (Apelação n.º 1.028.799/1, Julgado em 01/10/1.996, 4ª Câmara, Relator: - Canellas de Godoy, RJTACRIM 34/315).

Quarto: os atos de reconhecimento realizados não foram corroborados por outras provas.

O réu não foi submetido a reconhecimento pessoal logo após os fatos e nem, muito menos, em ato conforme às exigências formais do art. 226 do CPP.

O réu não foi preso em flagrante.

O réu não foi encontrado na posse de bens da vítima nem de outros objetos relacionados à prática dos fatos descritos na denúncia em circunstâncias que evidenciassem o envolvimento do acusado com a prática do crime de roubo, pelo que não se pode excluir a possibilidade de serem outros os autores dos fatos.

Portanto, a ação deve ser julgada improcedente, diante da ausência de provas suficientes para condenação, ausentes outros elementos de convicção, ainda que circunstanciais, indicativas de autoria da infração atribuída ao acusado, sob pena de cometimento de eventual injustiça. Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as

formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as

declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se defluiu da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). Grifo nosso. Assim, os atos de reconhecimento realizados nas fases de inquérito policial e processual são nulos porque realizados de forma diversa daquela prevista no art. 226 do CPP e não há no processo outras provas que relacionem o réu à prática do roubo descrito na denúncia pelo que não se pode excluir a possibilidade de sua inocência.

Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver LUCIANO SOARES GUIMARÃES, filho de Aprigio Humbuzeiro Guimarães e de Izaura Soares Guimarães, da imputação contida na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários da ilustre Defensora dativa.

P. e I.

Vinhedo, 28 de março de 2022.

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.